

第4節 性的自由・感情に対する罪

刑法
No240

予備独自問題 H24-11

(配点: 2)

月	日
月	日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを1個選びなさい。

1. 甲は、V女に対し、不同意性交をした後、同女から金品を奪う意思を生じ、同女に暴行・脅迫を加え、その反抗を抑圧して同女の財布を奪った。甲には強盗・不同意性交等既遂罪は成立しない。(改)
2. 甲は、V女に暴行を加えて同意しない意思を形成、表明又は全うすることを困難にさせた上で性交しようと思い、同女の顔面を1回殴ったところ、同女に逃げられ、性交することはできなかったが、前記殴打行為により同女に全治約1か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負わせた。甲には不同意性交等未遂罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。(改)
3. 甲は、強制的性交するために反抗を著しく困難にする程度の暴行をV女に加えたところ、その暴行により同女が脳震とうを起こして失神した。甲は失神した同女を性交した。甲には準強制的性交等既遂罪が成立する。(解答不能)
4. 甲は、16歳のV女を15歳であると誤信したまま、暴行・脅迫その他の行為又は事由により同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせることなく、又そのような状態にあることを利用せず同女を性交した。甲には不同意性交等既遂罪は成立しない。(改)
5. 甲は、不同意性交するため、殺意をもってV女に強度の暴行を加え、同女の同意しない意思を形成、表明又は全うすることを困難な状態にさせた上で同女を性交し、同暴行により、同女を死亡させた。甲には不同意性交等致死罪のみが成立する。(改)

No240	不同意性交等罪	正答率
予備H24-11	正解	39%
	4	

1 誤っている

241 条1項後段は、「第177条の罪……を犯した者が強盗の罪……をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。」と規定している。そのため、本記述では、強盗・不同意性交等既遂罪が成立する。

2 誤っている

最判昭23.11.16、最決昭43.9.17。181条2項は、「第177条〔注：不同意性交等〕若しくは第179条第2項〔注：監護者性交等〕の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。」と規定している。そして、判例は、本罪の成立には、性交等行為の既遂・未遂を問わないとしている（最判昭23.11.16）。また、判例は、本罪の致傷の結果については、性交等行為から生じた場合のみではなく、手段たる暴行から生じた場合も含まれるとしている（最決昭43.9.17）。よって、本記述では、不同意性交等致傷既遂罪の一罪が成立する。

3 解答不能

本肢の当時の出題意図は、準強制性交等罪が成立するのか強制性交等罪が成立するのかを問うものであり、準強制性交等罪で予定されている心神喪失若しくは抗拒不能の状態は、強制性交等罪で予想されるような暴行・脅迫によるものであってはならず、暴行・脅迫がある以上は強制性交等罪となるということが理解できているかを問うものだった。それが令和5年の刑法改正により「準強制性交等罪」「強制性交等罪」という罪名は無くなり、両者とも「不同意性交等罪」として整理されたため、本記述は解答不能となった。

4 正しい

177条3項、同1項は、16歳未満の者に対し性交等をした者について、暴行・脅迫その他の行為又は事由により同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした者に不同意性交罪の成立を認めている。本記述では暴行・脅迫その他の行為や状態は無いので177条1項の客観的構成要件を充足していない。また、V女は16歳であるから、甲がV女が15歳と誤信したとしても177条3項の客観的構成要件を充足しない。よって、本記述では、不同意性交等既遂罪は成立しない。

5 誤っている

大判4.12.11。殺意を有しつつ暴行により人と性交し死亡させた場合の罪責について、判例は、不同意性交等致死罪と殺人罪の観念的競合とする。判例の結論に賛成する学説は、致傷の場合に傷害の結果について認識があるときは刑の不均衡を是正するため不同意性交等致傷罪と傷害罪の観念的競合を認めることを前提に、刑事学的な犯罪類型として致傷と致死で区別して考えるべきではないということを挙げている。よって、不同意性交等致死罪と殺人罪が成立し、観念的競合となる。